



Roj: **SAN 699/2015 - ECLI:ES:AN:2015:699**

Id Cendoj: **28079230042015100034**

Órgano: **Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **4**

Fecha: **18/02/2015**

Nº de Recurso: **32/2014**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **PROCEDIMIENTO ORDINARIO**

Ponente: **MANUEL FERNANDEZ-LOMANA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA NACIONAL

Sala de lo Contencioso-Administrativo

SECCIÓN CUARTA

Núm. de Recurso: 0000032 / 2014

Tipo de Recurso: PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Núm. Registro General: 00412/2014

Demandante: D. Cesareo Y D^a Beatriz

Procurador: D^a MARÍA BLANCA RUEDA QUINTERO

Demandado: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL

Abogado Del Estado

Ponente Ilmo. Sr.: D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA

SENTENCIA N.º:

Ilma. Sra. Presidente:

D^a. MARÍA ASUNCIÓN SALVO TAMBO

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA

D^a. ANA MARTÍN VALERO

Madrid, a dieciocho de febrero de dos mil quince.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, se ha tramitado el recurso nº 32/2014 seguido a instancia de D. Cesareo y D^a Beatriz (herederos de D. Olegario) que comparecen representados por la Procuradora D^a. Blanca Rueda Quintero y dirigido por Letrado D. Alfonso Jaúdenes Piferrer, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, siendo demandada la Administración del Estado, representada y defendida el Sr. Abogado del Estado. La cuantía asciende a 17.402.974,94 €.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 27 de enero de 2014 tuvo entrada recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 3 de octubre de 2013 (RG 00818,817,1355 y 1356/2013) que confirmó las Resoluciones del TEAR de Madrid de 28 de noviembre de 2012 (28/26747/2010 y 28/26748/2010), promovidas contra el acuerdo dictado el 11 de mayo de 2010 por el que se desestimó el



recurso de reposición interpuesto ante la Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid contra el acuerdo de liquidación dictado el 10 de marzo de 2010, correspondiente al IRPF del ejercicio 2005 del sujeto pasivo D. Olegario , del que resultó una deuda tributaria de 16.466.845,27 €. Y la Resolución del TEAR de Madrid de 28 de noviembre de 2010 (28/26888/2010 y 28/26889/2010), promovidas contra el acuerdo dictado el 11 de mayo de 2010 por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid contra el acuerdo de liquidación dictado el 10 de marzo de 2010, correspondiente al IRPF del ejercicio 2006 del sujeto pasivo D. Olegario , del que resultó una deuda tributaria de 936.128,37 €.

SEGUNDO.- Recibido el expediente se formalizó demanda el día 14 de abril de 2014, solicitando la revocación de la resolución recurrida y la anulación de las liquidaciones practicadas con condena en costas de la Administración. Por escrito de 5 de mayo de 2014 la Abogacía del Estado se opuso a la estimación de la demanda.

TERCERO.- Practicada la prueba, se presentaron escritos de conclusiones los días 6 y 20 de junio de 2014, señalándose para votación y fallo el día 11 de febrero de 2015.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. MANUEL FERNÁNDEZ LOMANA GARCÍA, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTO DE DERECHO

PRIMERO.- Se interpone recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 3 de octubre de 2013 (RG 00818,817,1355 y 1356/2013) que confirmó las Resoluciones del TEAR de Madrid de 28 de noviembre de 2012 (28/26747/2010 y 28/26748/2010), promovidas contra el acuerdo dictado el 11 de mayo de 2010 por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto ante la Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid contra el acuerdo de liquidación dictado el 10 de marzo de 2010, correspondiente al IRPF del ejercicio 2005 del sujeto pasivo D. Olegario , del que resultó una deuda tributaria de 16.466.845,27 €. Y la Resolución del TEAR de Madrid de 28 de noviembre de 2010 (28/26888/2010 y 28/26889/2010), promovidas contra el acuerdo dictado el 11 de mayo de 2010 por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto por la Inspección Regional de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid contra el acuerdo de liquidación dictado el 10 de marzo de 2010, correspondiente al IRPF del ejercicio 2006 del sujeto pasivo D. Olegario , del que resultó una deuda tributaria de 936.128,37 €.

En su demanda, la parte demandante plantea, esencialmente, dos cuestiones: en primer lugar sostiene el fallecido no fue residente en España, sino en Suiza; y, en segundo lugar, que las cantidades derivadas de determinados pagarés no pueden ser calificadas como ganancias sin previa transmisión, pues se correspondían con préstamos efectuados al fallecido por la entidad URBESPAIN SA.

SEGUNDO.- El art. 9.4 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y cuya aplicación al caso de auto no se discute, establecía que: "Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias: a.- Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios de los calificados reglamentariamente como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural. Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las Administraciones públicas españolas. b.- Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél".

No es infrecuente que el contribuyente alegue que ha residido "fiscalmente" en otro país. En estos casos corresponde a la Administración aportar datos de los que se infiera la existencia de domicilio fiscal en España de conformidad con lo establecido en la Ley, si tales indicios son suficientes, corresponde al obligado tributario, demostrar su residencia en otro Estado. Por lo demás, el criterio de la residencia - *habitual abode* - es un criterio seguido a nivel internacional con carácter general por otros Estados.

En esta línea, con claridad, la **STS de 16 de junio y 13 de octubre de 2011 (Rec. 4029 y 2283/2008)**, recuerda que es doctrina constante de la Sala que "establecida la presunción ["se entenderá"], correspondía a la parte

demostrar la residencia en otro Estado". Regla que no es sino una razonable aplicación de la distribución de la carga de la prueba en materia tributaria, pues siendo cierto que corresponde a la Administración probar "los hechos en que descansa la liquidación impugnada", no lo es menos que "cuando la liquidación tributaria se funda en las actuaciones inspectoras practicadas, que constan debidamente documentadas, es al contribuyente a quien incumbe desvirtuar las conclusiones alcanzadas por la Administración". Y así, en la **STS de 16 de junio de 2011 (Rec. 4029/2008)** se sostiene que es obligación del "sujeto sometido a comprobación de probar su residencia fuera de España cuando la Administración lo ha considerado residente en nuestro territorio". Lógicamente porque se ha probado la existencia de sólidos indicios que llevan a tal conclusión.

Recuérdese, por lo demás, que una vez acreditada la residencia en España por más de 183 días durante el año natural -normalmente por pruebas indiciarias o indirectas-, al no tenerse en cuenta las "ausencias esporádicas", es necesario que el contribuyente acredite su "residencia fiscal" en otro país.

También ha indicado la Sala, entre otras en su **STS de 11 de noviembre de 2009 (Rec. 8294/2003)** que, en relación con el concepto de residencia, se exige, de un lado, "un elemento espiritual, la "intención" de residir en un lugar determinado. De otra parte, es necesario que se dé un elemento material, la residencia efectiva. La doctrina de la Sala 1ª sobre este problema ha vacilado entre dar relevancia al elemento subjetivo o al objetivo. En materia fiscal y para el legislador de 1978 no ofrece dudas que el elemento relevante es el elemento objetivo. Por eso el artículo....alude al elemento objetivo de la "permanencia" como rasgo definidor de la residencia".

En cuanto al criterio del "centro de intereses económicos" y personales -"se presumirá...que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando....residan habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél"-, la jurisprudencia pondera la importancia del patrimonio económico y la actividad económica desplegada - **STS 4 de julio de 2006 (Rec. 955/2010)** -.

TERCERO.- Aunque la residencia se discute tanto en relación con el ejercicio del IRPF de 2005, como el del 2006, los términos del debate no son idénticos.

Llegados a este punto es necesario analizar los hechos con base a los cuales la Administración ha llegado a la convicción de que durante el ejercicio 2005 el fallecido residió habitualmente en territorio español a los efectos del art 9 del Real Decreto 3/2004 .

En concreto, la Administración ha probado que la esposa del sujeto pasivo es propietaria de un inmueble sito en Pozuelo de Alarcón, siendo dicho inmueble "domicilio habitual familiar" según se manifestó en la escritura pública otorgada en 1999 y en cuyo acto de otorgamiento compareció el fallecido para otorgar su consentimiento. Dicho inmueble, en noviembre de 1999, se aportó a la Sociedad Urbanizaciones Pozuelo SL -sociedad patrimonial cuyo único activo es el inmueble-. La esposa del fallecido es titular de 99,79% de dicha sociedad y administradora única. El Servicio de Empadronamiento del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el 22 de noviembre de 2008, emitió certificado indicando que constaban domicilios en el referido inmueble el fallecido -sujeto pasivo-, su esposa e hijos y en el Padrón municipal, desde el 1 de mayo de 1996 y hasta la fecha de su emisión.

El inmueble estaba habitado, como se infiere de las facturas emitidas por Seguritas Direct -ejercicios 2005 a 2008-; consumo de agua 2005 a 2008, pagadas con cargo a c/c de la esposa y en la que consta autorizado el esposo; electricidad 2005 a 2008, pagados por c/c a nombre del hijo y en la que está autorizado el fallecido; facturas de teléfono de 2004 a 2007; certificado de la TGSS de empleados del hogar por el periodo 2003 a 2009.

En extractos de c/c de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, constan movimientos de cuenta descritos en el acta, relativos a la esposa, hijos y el fallecido (por cargos del Club Las Encina de Boadilla; Clínica Cisne Seguros SA y Seguritas Directa España SA). En esa misma cuenta se efectuaba el cobro de la pensión del sujeto pasivo por el periodo 2005 a 2008.

Se describen, además, transferencias realizadas desde España a Luxemburgo y retirada de efectivo en entidad bancaria situada en España. El titular de dichas cuentas es el sujeto pasivo y los importes oscilan entre 16.300.000 € y 609.000 €. Todas ellas en el ejercicio 2005 y por un total de 26.717.000 €.

Se describen en el acta, movimientos dinerarios a cuentas bancarias del sujeto pasivo durante el ejercicio 2005, bien con entrada en cuentas del sujeto pasivo (transferencia) o bien mediante cheques nominativos a favor del sujeto pasivo. Las operaciones oscilan entre 3.500 y 2.923.000 € y suponen un total de 29.939.384 €.

Ser razona, además por la Administración y así consta probado tras verificación por esta Sala que:

-El 18 de febrero de 2005 cobró por caja dos talones de 250.000 y 1.800.000 €. Realizando ingresos los días 23, 24 y 28 de febrero; así como el 18 de junio mediante cheques nominativos.

-También firmó órdenes de transferencia en España los días 8 de julio de 2005 (25.000.000 €) y el 12 de septiembre por un total de 609.000 €.

-Constan consultas externas en el Hospital Puerta de Hierro los días 21 de junio, 3 de octubre y 11 de noviembre de 2005.

-Uso de tarjetas en comercios y locales por el fallecido los días 9 de abril; 9 de junio; 1,4,8,12,17, 20, 23, 27 y 29 de julio; 30 de septiembre; 3, 6, 7,10, 11 y 13 de octubre; 2,11,12,14,18,20. 22, 24, 26, 28, 29, 30 y 31 de diciembre de 2005.

-La autorización de estancia en Suiza se expide el 14 de octubre de 2005 y el 14 de diciembre de 2005 es cuando comunica a la Administración española el cambio de residencia.

Es por todo ello claro, en opinión de esta Sala que existen indicios claros de que el residente reside en España más de 183 días, sin que haya podido desvirtuar los datos aportados por la Administración. Sin que pueda ser óbice a tal conclusión la aportación de una serie de facturas correspondientes a un alquiler de un estudio en Ginebra o la documentación sobre la contratación del seguro médico en Suiza, frente al conjunto de datos aportados por la Administración española.

Siendo suficiente lo anterior para afirmar la residencia en el año 2005 es que, además, consta a efectos de determinar el "núcleo principal o base de sus actividades o intereses económicos" que, además de no aportarse por los herederos datos de sus actividades económicas en Suiza:

-Como hemos dicho constan los movimientos dinerarios antes descritos, siempre en España.

-El fallecido era administrador único de la entidad UBRBESPAIN SA -capital social de 5.004.000 €- hasta su fallecimiento, cuyo capital, en su totalidad, pertenecía a ESTUDIOS URBANISTICOS MADRILEÑOS SL, cuyo capital se encontraba a nombre de los hijos del sujeto pasivo. Esta entidad, en 2005 transfirió al sujeto pasivo 17.733.284 €. La actividad de la entidad era la promoción inmobiliaria de terrenos.

-El fallecido era socio mayoritario de GRUPO PROCOVIF FORCOMI SA, ostentando el 99,96 € del capital desde 1998 y hasta su fallecimiento, en 2005 dicha entidad transfirió al sujeto pasivo 7.133.000 €. La actividad esta la prestación de servicios propios de la Propiedad inmobiliaria.

-El fallecido era administrador único de INMOBILIARIA EUROCENTRO SA desde 2001 y hasta su fallecimiento. El 99% del capital pertenecía a ESTUDIOS URBANISTICOS MADRILEÑOS SL, de esta entidad obtuvo en 2005 3.372.000 €.

-Es apoderado de ESTUDIOS URBANISTICOS MADRILEÑOS SL, cuyo capital corresponde al 100% a sus hijos, hasta su fallecimiento. Esta entidad tenía una importante actividad y las sumas obtenidas de la misma por el sujeto pasivo ascendieron a 2.700.000 €.

Ante tales datos, la Sala sólo puede concluir que durante el ejercicio 2005 el fallecido residió en España.

CUARTO.- Pues bien, como razona el TEAC, con relación al ejercicio 2005, la primera cuestión que debe resolverse es si "los sucesores del sujeto pasivo...acreditaron, en el curso de las actuaciones inspectoras, que el sujeto pasivo tenía su residencia fiscal en Suiza". Antes, sin embargo, de analizar las concretas circunstancias del caso conviene dejar claro que la "residencia" que debe acreditar un recurrente en otro país es la "residencia fiscal"; por lo que su acreditación debe tener dicho carácter y, en principio, no se puede dar eficacia a certificados de residencia de otro tipo, pues una persona puede obtener permiso de residencia o tener reconocida residencia administrativa en un Estado extranjero, sin que por ello haya de ser considerado como residente a efectos fiscales en ese Estado. Se considera que una persona tiene residencia fiscal en un determinado Estado, cuando está sujeto a tributación en él por obligación personal. De aquí la importancia de la certificación que se aporte al efecto en el que debe quedar claro que quien aporta el certificado es residente fiscal en otro país y el periodo al que se refiere dicha residencia. Dicho de otro modo, una persona tiene residencia fiscal en un determinado país cuando está sometido a imposición en él por obligación personal, esto es, por su renta mundial, por lo que la demostración de tal hecho exige aportar el certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal competente de ese país, en el que conste tanto su permanencia como sus obligaciones fiscales en el mismo.

La Sala no ignora que la doctrina científica ha criticado, en ocasiones, la rigidez de la prueba exigida por la Administración para acreditar la residencia fiscal: certificado que se refiera específicamente a la residencia fiscal; que se emita por la Administración tributaria y que especifique que el contribuyente tributa en ese país por la renta mundial. Pero sin perjuicio de que en algún caso concreto y en atención a las circunstancias concurrentes podamos admitir otro tipo de pruebas para acreditar la residencia habitual - **SAN (2ª) de 28 de noviembre de 2002 (Rec. 273/2000)-**, como veremos, el caso de autos no ofrece dudas.

En concreto y con relación al año 2005 el fallecido comunicó su cambio de residencia a Suiza en diciembre de 2005 -esta comunicación sería en todo caso irrelevante visto que se produjo en diciembre de 2005 (**STS de 11 de noviembre de 2009 -Rec 8294/2003**)-. Consta, asimismo, que inicialmente aportó un certificado en la que las autoridades fiscales suizas (*Administración fiscale cantonale de la République et Canton de Geneve*), a fecha 30 de abril de 2009, señala que con fecha de dicho certificado el fallecido esta sujeto de forma ilimitada a los impuestos del cantón, todo ello hasta el 23 de julio de 2008 -fecha del fallecimiento-. Siendo claro que dicho certificado no indica desde que fecha se encuentra sujeto a los impuestos del cantón y, más en concreto, no se hace ninguna referencia al año 2005.

Constan diligencias de fecha 28 de mayo, 10 de junio y 22 de julio de 2009 en las que se advirtió de éste extremo al compareciente ante la Inspección. Siendo posteriormente, en alegaciones, cuando el recurrente aporta un nuevo certificado emitido por las autoridades fiscales suizas (*Administración fiscale cantonale de la République et Canton de Geneve*), de fecha 23 de mayo de 2006, que señala que a la fecha del certificado está sujeto de forma ilimitada a los impuestos del cantón.

Por lo tanto, en opinión de la Sala, es claro que en el ejercicio 2005 el causante no era residente a efectos fiscales en Suiza. Los argumentos de la recurrente acreditan que el fallecido tenía una autorización de estancia (*Autorisation de séjour*), sin actividad lucrativa, pero no podemos considerar que de dicho documento se infiera la existencia de residencia fiscal. De hecho, en su demanda, trata de dar el mismo tratamiento al periodo 2005 que al 2006, pero por lo que hemos razonado y compartiendo el criterio de la Administración, esta forma de proceder no es correcta, pues la residencia fiscal en Suiza sólo se acredita respecto del ejercicio 2006, como luego veremos, y así lo acepta la Administración.

En suma, la Administración en relación con el ejercicio 2005 prueba de forma razonable que el fallecido residió en España con arreglo a lo establecido en el art 9 del Real Decreto Legislativo 3/2004 . Y, el recurrente, no prueba que durante dicho periodo residiese fiscalmente en Suiza. Lo que hace innecesario acudir al Convenio de 26 de abril, ratificado por Instrumento de 26 de enero de 1967, suscrito entre el Estado Español y la Confederación Suiza para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio.

QUINTO- El debate, como indicamos con anterioridad, es distinto en relación con el ejercicio 2006. Pues, en éste ejercicio, en el escrito de alegaciones presentado ante la Oficina Técnica, se acompañó un certificado expedido por las autoridades fiscales suizas (*Administración fiscale cantonale de la République et Canton de Geneve*), de fecha 23 de mayo de 2006, que señala que a la fecha del certificado, el hoy fallecido, estaba sujeto de forma ilimitada a los impuestos del cantón. No hay duda, por lo tanto y así lo reconoce la Administración española, que en el ejercicio 2006, el obligado tributario era residente fiscal en Suiza.

Pues bien, el Convenio de 26 de enero de 1967, suscrito entre el Reino de España y Suiza establece en su art 4.1 que "a los efectos del presente Convenio, se considera «residente de un Estado contratante» a toda persona que, en virtud de la legislación de este Estado, esté sujeta a imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga".

Añadiendo el art. 4.2 que: "Cuando en virtud de las disposiciones del párrafo 1 una persona física resulte residente de ambos Estados contratantes, el caso se resolverá según las siguientes reglas: a.- esta persona será considerada residente del Estado contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales); b.- si no pudiera determinarse el Estado contratante en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados contratantes se considerará residente del Estado contratante donde viva de manera habitual; c.- si viviera de manera habitual en ambos Estados contratantes o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado contratante del que sea nacional; d.- si fuera nacional de ambos Estados contratantes o no lo fuera de ninguno de ellos las Autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo".

Interpretando el alcance de esta norma la **STS de 15 de diciembre de 2005 (Rec. 702/2001) y 4 de julio de 2006 (Rec. 3400/2001)** ha establecido una doctrina que podemos resumir en los siguientes puntos:

1.- En el Convenio "el criterio determinante de la potestad tributaria entre los dos países firmantes, en lo que a las personas físicas se refiere, es el de la residencia. Pero el Convenio no impone un concepto de residencia habitual para considerar a una persona «residente de un Estado contratante», sino que deja a la legislación interna de cada uno de los Estados contratantes la determinación de quien se considera «residente» sujeto a la imposición de cada uno de los Estados contratantes".

2.- "Precisamente porque el Convenio deja a la legislación interna de cada Estado la determinación de la residencia habitual en el territorio de cada uno de ellos, es evidente que, con independencia de que la Administración fiscal del cantón de Ginebra atribuya la condición de residente en Suiza del recurrente, también por aplicación del art. 4.1 del Convenio de Doble Imposición ,..., el recurrente puede ser considerado igualmente residente en España",

3.- En suma, "la remisión a la legislación interna de cada Estado contratante puede conducir a que una persona pueda ser considerada residente en cada uno de los dos Estados contratantes; por eso, el Convenio entre Suiza y España de 26 de abril de 1966 establece una serie de reglas para resolver los casos en que una persona física resulte residente de ambos Estados".

4.- En supuestos de "doble residencia fiscal" es preciso "acudir al apartado 2 del art. 4 del Convenio para resolver la problemática planteada". Por lo tanto, si el recurrente es residente fiscal en España, "con arreglo a la legislación interna española, quedaría cabalmente planteado un supuesto de doble residencia fiscal, que obliga a acudir a las reglas previstas en el art. 4.2 del Convenio".

5.- Por último, la Sala rechaza que acreditado por el recurrente que se tenga la residencia en Suiza "no puede entrar en aplicación el apartado 2 del art. 4 del Convenio porque no se da la premisa prevista de doble residencia fiscal. Y no es admisible el alegato porque es innegable que el criterio utilizado por la legislación interna española para determinar la sujeción por obligación personal es el de la residencia, acorde pues a lo dispuesto en el apartado 1 del art. 4 del Convenio, sin que en éste se entre a cuestionar cuáles sean los criterios que la legislación de cada Estado aplique para estimar que se da esa residencia; resulta así inane la crítica que el recurrente hace acerca de que el criterio del centro de intereses económicos no se contempla en el apartado 1 del art. 4 del Convenio. El argumento de que, a diferencia del Modelo de Convenio de Doble Imposición sobre la Renta y el Patrimonio de la OCDE , que contempla el criterio que denomina «centro de intereses vitales» únicamente como subsidiario para resolver los conflictos de doble residencia entre Estados contratantes, nuestra Ley...lo elevó a norma de rango general, determinante, por sí solo, de la residencia habitual del sujeto pasivo, es un argumento sólo planteable en el ámbito de «lege ferenda», pero al que no puede atenderse en el marco de «lege data», aunque se considere, doctrinalmente, como un desacierto porque, en lugar de aproximarse al Modelo de Convenio de OCDE, se aleje de él, criterio doctrinal que no puede ser admitido acriticamente pues la propia Memoria del Proyecto de la que fue la Ley....afirmaba que la consideración del centro de intereses económicos como definidor de la residencia habitual a efectos del IRPF supone un cierto avance de la legislación española, fundamentada en la experiencia adquirida e inspirada en la línea seguida por la OCDE. De modo que el centro de intereses vitales es una circunstancia válida, con arreglo a la legislación del Estado español..., para determinar la residencia fiscal a efectos del art. 4.1 del Convenio de Doble Imposición , no un criterio para resolver la doble residencia".

En concreto, en las dos sentencias citadas, el recurrente probó que tenía viviendas a su disposición en España y Suiza, por lo que en aplicación del art. 4.2.a) deba considerarse al recurrente residente de aquel Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas. Este criterio atiende a una pluralidad de circunstancias: personales, familiares, sociales, económicas, etc". Llegando la Sala a la conclusión, en ambos supuestos, de que el recurrente era residente en España no en Suiza, siendo "España a la que cabe considerar como país de residencia y donde le corresponde tributar al recurrente".

SEXTO.- De lo expuesto en el anterior fundamento de Derecho se infiere que resulta esencial determinar si el sujeto pasivo tenía su residencia habitual en territorio español en el año 2006. Pues, de ser así, estaríamos ante un supuesto de doble residencia, debiendo aplicar los criterios establecidos en el art. 4.2.a) del Convenio para resolver el conflicto.

Para el TEAC, como se ha probado la "residencia fiscal" en Suiza, ya no resulta posible aplicar el criterio del 9.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2004, pues aunque "se puede constatar la presencia casi constante del sujeto pasivo en territorio español, no se alcanza la permanencia durante 183 días en el ejercicio 2006, al no poderse computar las ausencias esporádicas del sujeto pasivo en ese ejercicio 2006, y ello por mandato expreso de dicho precepto, que impide dicho cómputo cuando el contribuyente acredita su residencia fiscal en otro país". Esta forma de proceder nos parece acertada, en efecto, la normativa vigente no exige probar que se ha permanecido en otro país más de 183 días, sino acreditar la condición de residente fiscal en otro país, por lo que acreditada tal residencia, no puede tenerse en cuenta el criterio establecido en el art. 9.4.a) del Real Decreto Legislativo 3/2004 .

Por ello se centra en lo establecido en el art. 9.4.b) del Real Decreto Legislativo 3/2004 , conforme al cual se también se considera residente cuando "radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta". Y en este punto la Administración destaca:

-Que los herederos del sujeto pasivo no han aportado prueba alguna que acredite que el sujeto pasivo tuviese actividades o intereses económicos en Suiza. De hecho, en su autorización de estancia en Suiza consta la expresión " *sans activité*".

-Que el fallecido seguía siendo administrador único de URBESPAIN SA hasta su fallecimiento; que era socio mayoritario del GRUPO PROCOVIF FORCOMI SA - ostentando el 99,96% del capital- y socio administrador único hasta su fallecimiento, desplegando dicha entidad una intensa actividad económica; que era administrador único de INMOBILIARIA EUROCENTRO SA hasta su fallecimiento; que era apoderado de ESTUDIOS URBANISTICOS MADRILEÑOS SL hasta su fallecimiento; que era, hasta su fallecimiento, administrador único de CONSTITUTUM SA, ASESORIA FORCOMI SL, PROESTUN SA, PLANIMEN SL y GRANSUP SL. Por último, era autorizado en cuentas bancarias de le empresas en que era socio y administrado y, además en: SOCIEDAD COOPERATIVA ARAVACA IV, SOCIEDAD COOPERATIVA ARAVACA II, SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA NUEVA CASTELLANA II, SOCIEDAD COOPERATIVA NUEVA CASTELLANA, NUEVA CASTELLANA SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS, PLANIFIC SA, PLANIFICADORA ALIMENTARIA SA y SOCIEDAD

COOPERATIVA DE ARAVACA.

Por lo tanto, la Sala, con el TEAC sostiene que en aplicación del art. 9.4.b) del Real Decreto Legislativo 3/2004, el fallecido era residente fiscal en España. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, de forma similar a los países de nuestro entorno, el legislador, para determinar cuando puede considerarse a un contribuyente como "residente habitual", utiliza varios criterios de forma concurrente, bastando por lo tanto que concurra uno de ellos para que la persona física afectada tenga la consideración de residente. Pues bien, nuestra legislación utiliza el criterio de "actividades o intereses económicos" para determinar la residencia fiscal, debiendo estarse al examen de las rentas y patrimonio del contribuyente para determinar cuando sus actividades e intereses se encuentran en España. Ahora bien, la norma exige además, que dichos intereses sean principales, pues el contribuyente puede tener actividades e intereses en otros países. Pues bien, para verificar esta nota debe realizarse un análisis comparativo entre los intereses en España y los intereses en otros Estados considerados de forma individual - **STS de 4 de julio de 2006 (Rec. 3400/2001)** -. Por lo demás, acreditada la existencia de un núcleo esencial de actividad e intereses en España, es carga del contribuyente aportar datos de los que pueda razonablemente inferirse que pese a la actividad en territorio español dicha actividad no puede calificarse como principal.

Pues bien, si aplicamos la anterior doctrina al caso de autos, la Sala no tiene dudas de que los intereses y actividades económicas del recurrente se encontraban en España, máxima cuando no se aportan pruebas en sentido contrario, que puedan desvirtuar la anterior convicción.

SÉPTIMO.- Siendo el fallecido residente fiscal en España, procede en aplicación de la doctrina antes descrita, procede acudir a lo establecido en el art. 4.2 del Convenio para resolver el conflicto, pues el sujeto obligado es residente a efectos fiscales tanto en España como en Suiza.

Conviene recordar que, conforme hemos descrito, la "persona será considerada residente del Estado contratante donde tenga una vivienda permanente a su disposición. Si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado contratante con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)".

La Administración razona que, en contra de lo que sostienen los demandantes, el fallecido si tenía una "vivienda permanente a su disposición" en España. Para ello basta con que nos remitamos a lo ya razonado para el ejercicio 2005, que también resulta aplicable al ejercicio 2006 -recuérdese que el fallecido constaba empadronado como residente en la vivienda antes descrita; que según se indicó en escritura por ambos cónyuges, ese era el domicilio familiar; que se acreditaron gastos que prueban que en el periodo debatido la vivienda estaba ocupada -gastos de luz, agua, teléfono, seguridad, empleadas de hogar, seguros, etc.-.

A lo que cabe añadir que la esposa del fallecido era miembro de la Asociación Parkinson de Madrid hasta el año 2009, asistiendo a sesiones desde el 13 de enero de 2006 y hasta el 28 de febrero de 2007 y a sesiones de logopedia desde el 13 de enero de 2006 al 24 de abril de 2009; y rehabilitación a domicilio desde el 3 de septiembre de 2006 al 16 de abril de 2009. Que el sujeto pasivo era socio del Club Las Encinas de Boadilla durante los años 2005 a 2008 y el domicilio que consta es el de la vivienda antes descrita. Consta que también mantenía una póliza de gastos de entierro en España. Que era miembro de la Hermandad de Caballeros de San Fernando desde el 27 de noviembre de 2005 al 2007. Y Caballero Numerario, en la Real Asociación de Caballeros del Monasterio de Yuste en el periodo 2005/2008. Durante los años que manifiesta residir en Suiza consta también que tenía asignado, "por su domicilio", como centro hospitalario de referencia el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Pues bien, todas estas razones nos llevan a concluir que el fallecido tenía residencia permanente - *permanent home*- en España. Manteniendo en España "relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)".

Por lo tanto, la Sala confirma el criterio mantenido por el TEAC al ser conforme a Derecho.

OCTAVO.- Por último, sostiene la parte demandante que, en relación con el ejercicio 2005, no se ha tenido en cuenta que en los años 1997 y 1999 fueron formalizados préstamos que dieron lugar al reconocimiento de deuda de la sociedad URBESPAIN SA y a los pagarés de cuenta corriente que acreditan la concesión de un préstamo a favor del Sr. Olegario -la cantidad asciende a 16.000.000 €-. Al efecto se aportó el documento de reconocimiento de deuda y tres pagarés emitidos por BANKINTER por sumas de 1.000.000 €; 3.000.000 € y 12.000.000 €, emitidos el 29 de junio de 2005.

En relación con dichas cantidades la Dependencia de Inspección Oficina Técnica, no compartió la calificación de "ganancia de patrimonio no justificada", entendiendo que lo obtenido por el obligado tributario es "una ganancia sin previa transmisión por incorporación de bienes y derechos", pues consta acreditado que durante el ejercicio 2005 se produjeron una serie de ingresos -29.938.284 €- en sus cuentas bancarias procedentes de sus propias sociedades, sin conocerse con certeza si tales cantidades las percibió como socio o como administrador, de aquí que la Administración las calificase como "ganancia sin previa transmisión por incorporación de bienes y derechos".

Centrándonos en las transmisiones efectuadas por URBESPAIN el interesado aportó un documento en el que, además de contemplarse el devengo de intereses pactados con la Sociedad, se adquirió el compromiso de devolver las cantidades el 30 de junio de 2010, 30 de junio de 2012 y 30 de junio de 2015, acompañándose pagarés emitidos en 2005.

Consta que la Inspección requirió reiteradamente a URBESPAIN SA que no fueron atendidos. Consta, sin embargo, en el Registro que el administrador de la Sociedad fue D. Olegario desde el 2001 y hasta su fallecimiento. El capital de dicha entidad pertenece a ESTUDIOS URBANISTICOS MADRILEÑOS SL, entidad participada por los hijos de D. Olegario , un 49% del capital cada uno de ellos. No obstante, debe tenerse en cuenta que en marzo de 2003 vendieron todas sus acciones a otra entidad, permaneciendo el fallecido como administrador único. El único activo de la sociedad consistía en unos terrenos en Estepota (Málaga) cuya venta generó en el ejercicio 2003 unas ganancias que fueron declaradas -extemporáneamente- el 1 de julio de 2005, por importe de 11.934.509.14 € habiendo transferido unos días antes la cantidad de 16.479.362 € a Don Olegario . La sociedad no tiene actividad.

Pues bien, la Administración indica que habiéndose requerido por la Inspección al obligado tributario a que se justificase documentalmente el origen de tales fondos, no se atendió al requerimiento. Si bien, en fase de alegaciones se aportó un fotocopia de un documento privado de reconocimiento de deuda. Para la Inspección, el documento aportado no pasa de ser una declaración unilateral de voluntad que no presupone la existencia de aquella. Y lo mismo cabe decir respecto de los pagarés que son confeccionados por los bancos "conforme a modelos normalizados, y los entregan a sus clientes en forma de talonarios numerados que contienen el número de cuenta corriente así como e número de serie de cada pagaré". En suma, para la Administración "no ha quedado probado que los ingresos realizados en la cuenta bancaria del obligado tributario procedentes de URBESPAIN SA representen la concesión de un préstamo a su favor". Este criterio es confirmado por el TEAC.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un problema de prueba. En relación con la aportación de "documentos privados de reconocimiento de deuda" la **SAN (2ª) de 26 de mayo de 2005 (Rec. 1040/2002)** sostiene su insuficiencia a falta de otros elementos probatorios, pues "carecen de eficacia frente a terceros al no concurrir ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 1227 del Código Civil , pues como se expresa en la resolución combatida, dicho precepto únicamente se refiere a la eficacia frente a terceros de la fecha del documento desde el fallecimiento del firmante, pero no a la autenticidad del contenido del documento privado, dado que dicha autenticidad es propia de los documentos públicos, tal y como establece el artículo 1218 del referido Cuerpo Legal , a cuyo tenor "los documentos públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste....". Frente a dicha insuficiencia probatoria declarada tanto por los órganos de Inspección, como por los Tribunales Económico Administrativos, ninguna prueba ha practicado la parte recurrente en sede jurisdiccional,...que permitieran respaldar sus afirmaciones". En la misma línea, la **SAN (2ª) de 29 de abril de 2010 (Rec. 26/2007)** sostiene que "los documentos privados de parte interesada no hacen prueba frente a terceros".

Valorando la prueba aportada la Sala no puede compartir el criterio de la parte demandante por las siguientes razones:

1.- Lo que aportan los recurrentes, tras ser reiteradamente requeridos al efecto, no es el contrato privado de préstamo, sino un documento privado consistente en un reconocimiento de deuda, fechado el 29 de junio de 2005, por importe de 16.000.000 € y con el que tratan de justificar la entrega de 16.733.284 €. El reconocimiento se dice firmado por el sujeto pasivo.

2.- Dicha aportación no se realizó pese a los reiterados requerimientos hasta la fase de alegaciones. Así en diligencia de 28 de mayo de 2009 indicaron que no se habían encontrado documentos mercantiles que acreditasen los citados pagos. En diligencia de 10 de julio de 2009, se reiteró la justificación mercantil de tales pagos. Y en diligencia de 22 de julio se hace constar que no se aporta justificación mercantil de tales pagos.

3.- Es cierto que se aportan unos pagarés fechados el 29 de junio de 2005, parece ser que firmados por el fallecido. Para dar validez a los mismos, se indica que dicha copia ha sido cotejada por un notario y es cierto. Pero se omite decir que el cotejo se ha producido el 27 de noviembre de 2009, más de cuatro años después de la fecha que se consignó en el pagaré. Y por lo tanto, la intervención notarial no permite acreditar que dichos pagarés existiesen y estuviesen firmados antes del inicio de las actuaciones inspectoras.

En suma, estamos ante un documento puramente privado, que no permite, por sí mismo, dar fe de su fecha, ni de su contenido. Por lo que también en este punto procede desestimar el recurso. Recuérdese, por último, que los documentos privados no hacen prueba de su autenticidad si esta ha sido impugnada por la parte a quien perjudique art 326 LEC y **STS de 24 de noviembre de 2011 (Rec. 4914/2008)** -.

NOVENO.- Procede imponer las costas a la parte recurrente - art 139 LJCA -.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación, la Sala dicta el siguiente

FALLAMOS

Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora D^a. Blanca Rueda Quintero, en nombre y representación de de D. Cesareo Y D^a Beatriz (herederos de D. Olegario) contra la la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de fecha 3 de octubre de 2013 (RG 00818, 817, 1355 y 1356/2013), la cual confirmamos por ajustarse a Derecho. Con imposición de costas a la parte demandante.

Intégrese la presente sentencia en el libro de su clase y una vez firme remítase testimonio de la misma junto con el expediente administrativo al lugar de procedencia de éste.

Así por esta nuestra sentencia que se notificará a las partes haciéndoles saber, con las demás prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , que contra la misma cabe recurso de casación para ante la Sala tercera del Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el día mismo de su fecha, fue leída y publicada la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose constituida en Audiencia Pública, de la que yo, el Secretario, doy fe.